

1500590-75.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Torres de Aguiar

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/04/2022

... quanto ao crime de associação para o tráfico. Quanto ao corréu Paulo, pugnou pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito tipificado no artigo 28 da Lei de Tóxicos, bem como sua absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes ficou comprovada pelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

1ª Vara Criminal

Rua Jacob Emmerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às18h00min

1500590-75.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500590-75.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS LOPES DA SILVA e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Torres de Aguiar

Vistos.

MATEUS LOPES DA SILVA e PAULO ALBERTO QUINTINO DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, e no artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia, em ocasião de calamidade pública, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta, ainda, que, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas na exordial, em ocasião de calamidade pública, o acusado PAULO trazia consigo, para fins de tráfico, 25 pedras de crack, substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, enquanto o acusado MATEUS trazia consigo, para fins de tráfico, 112 pedras de crack, 16 porções de espécie de maconha conhecida como "k4" e 150 pinos contendo cocaína, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Foi também apreendida com MATEUS

a quantia de R\$42,00.

Os réus foram notificados e apresentaram defesas preliminares. A denúncia foi recebida e os réus foram citados.

Durante a instrução, foi ouvida uma das testemunhas policiais arroladas na denúncia, sendo homologada a desistência das partes quanto à oitiva da segunda testemunha policial. Ao final, foram os réus interrogados.

Encerrada a instrução, foram realizados os debates.

O Ministério Público pediu a procedência parcial da ação, com a condenação do acusado Mateus pela prática do crime de tráfico de drogas, porém, quanto ao corréu Paulo, requereu a desclassificação do crime para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas. Pleiteou, também, a absolvição de ambos os acusados quanto ao crime de associação para o tráfico. Quanto à dosimetria da pena relativa ao acusado Mateus, pediu a fixação da pena-base acima de seu mínimo legal, bem como o reconhecimento da circunstância agravante relativa à calamidade pública e sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Requereu a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, bem como a fixação do regime inicial fechado. Por fim, pediu o perdimento da quantia apreendida com Mateus.

A Defesa, por sua vez, deixou de requerer a absolvição quanto ao acusado Mateus pelo crime de tráfico de drogas, diante de sua confissão. Requereu, quanto a este réu, a fixação da pena-base em seu mínimo legal, o afastamento da circunstância agravante relativa à calamidade pública e o reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Pediu a aplicação da causa especial de diminuição de pena e a fixação do regime inicial aberto, com a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos. Pleiteou, outrossim, a absolvição do acusado Mateus quanto ao crime de associação para o tráfico. Quanto ao corréu Paulo, pugnou pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito tipificado no artigo 28 da Lei de Tóxicos, bem como sua absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes ficou comprovada pelo auto de exibição e apreensão, pelo auto de constatação, pelas fotografias de fls. 16/19, pelos laudos de exame químico-toxicológico, bem como pela prova oral produzida em Juízo.

Também não restam dúvidas quanto à autoria do delito, porém apenas quanto ao acusado Mateus.

Interrogado em Juízo, o acusado Mateus confessou a prática do crime de tráfico de drogas descrito na denúncia, porém disse que estava realizando a atividade com outro indivíduo, que não era o corréu Paulo. Disse que estava desempregado e, como necessitava ajudar na manutenção de seu lar, decidiu praticar o crime. Contou que havia vendido pedras de crack ao acusado Paulo, que ainda estava ao seu lado quando outro indivíduo também aproximou-se para comprar drogas. Disse que, nesse momento, os policiais realizaram a abordagem. Contou que Paulo havia adquirido 20 pedras de crack pelo valor de R\$100,00 e deu a ele, como brinde, cinco porções a mais do entorpecente. Admitiu que todo o entorpecente apreendido era de sua responsabilidade e disse que a droga era fornecida pelo indivíduo a quem conhece como Oliveira e que estava praticando o tráfico de drogas consigo naquele local. Disse que foi esse indivíduo quem recebeu o dinheiro do acusado Paulo, sendo que ele conseguiu fugir no momento da abordagem policial.

Interrogado em Juízo, o acusado Paulo negou a prática dos crimes descritos na denúncia. Disse que havia combinado com um conhecido de nome João que iriam consumir entorpecentes e, então, tendo cada um contribuído com R\$50,00, foi ao ponto de tráfico, enquanto seu conhecido João foi a um bar próximo comprar isqueiro e cigarro. Contou que o corréu Mateus estava praticando o tráfico e adquiriu dele 20 pedras de crack pelo valor de R\$100,00, tendo ganhado cinco porções a mais do mesmo entorpecente, os quais colocou em seu bolso. Alegou que não conhecia o acusado Mateus e contou que próximo a ele havia outro indivíduo, a quem entregou o dinheiro para a compra das drogas. Declarou que, no momento da abordagem policial,

o indivíduo que estava ao lado de Mateus fugiu. Disse que também correu até parar em frente a uma casa, onde foi abordado por um dos policiais. Contou ter dito a esse policial que havia adquirido as drogas momentos antes, mas foi algemado e levado com Mateus à delegacia. Disse que seu conhecido João estava em local próximo, mas foi embora quando ocorreram os fatos. Não soube dizer quem era o indivíduo que estava próximo a Mateus e a quem entregou o dinheiro. Declarou que não fazia uso de crack diariamente, mas teve recaída e alegou trabalhar com venda de lanches e açaí.

Corroborando a confissão do acusado Mateus, a testemunha policial Cláudio Nascimento Moraes, ouvida sob o crivo do contraditório, relatou que, durante diligência em local já conhecido pela ocorrência do tráfico de drogas, estacionou a viatura descaracterizada em ponto próximo, momento em que visualizou o acusado Mateus com uma sacola na mão, e viu o corréu Paulo ao lado dele. Disse que Paulo estava conversando com Mateus e com outras pessoas que por ali passavam. Narrou que, durante o monitoramento, viu um indivíduo aproximar-se de Mateus e entregar algo a ele, tendo visto, também, Mateus retirar da sacola que segurava algo que entregou àquele indivíduo. Declarou que, nesse momento, foi realizada a abordagem. Relatou que deteve Mateus, que permaneceu no local e estava em posse da sacola. Narrou que, em busca pessoal ao acusado Mateus, com ele nada foi encontrado, mas na sacola que ele segurava foram localizadas 112 pedras de crack, 150 pinos contendo cocaína e 16 porções de maconha, além da quantia de R\$42,00. Disse que o corréu Paulo empreendeu fuga no momento da abordagem e ingressou em uma casa, onde acabou sendo detido pelo policial Luciano, que o havia seguido. Declarou que o policial Luciano localizou no bolso do acusado Paulo 25 pedras de crack. Consignou que a campana foi realizada a cerca de 50 a 100 metros do local onde estavam os acusados e visualizou, de onde estava, a venda das drogas. Esclareceu que não foi possível realizar a abordagem do indivíduo que aproximou-se dos acusados para comprar entorpecentes. Narrou que a residência em que o acusado Paulo ingressou não pertencia a ele, mas estava com o portão aberto e ele lá entrou. Não soube dizer se havia outras pessoas nessa casa. Relatou que o acusado Mateus admitiu, informalmente, a prática do crime de tráfico de drogas, porém o corréu Paulo apresentou versões dissonantes, ora dizendo que estava realizando o tráfico, ora dizendo que as drogas em sua posse seriam para seu uso pessoal, ora dizendo que, além de serem para seu uso, também as venderia para amigos. Declarou que nenhum elemento que indicasse a associação prévia dos acusados foi apurada e consignou que os acusados nada disseram sobre estarem se auxiliando no tráfico de drogas. Narrou que, no momento da abordagem, havia duas pessoas que estavam próximas aos acusados, sendo uma delas o indivíduo que adquiriu drogas de Mateus, porém elas conseguiram fugir e a ação não foi presenciada por mais ninguém. Consignou que o monitoramento durou cerca de cinco minutos e, nesse ínterim, viu somente uma pessoa aproximar-se do acusado Mateus. Esclareceu que, nesse momento, o corréu Paulo estava ao lado de Mateus, mas não o viu realizar qualquer conduta relativa ao tráfico de drogas. Não há dúvidas, portando, sobre a conduta criminosa do acusado Mateus, quanto ao delito de tráfico de drogas a ele imputado, diante das provas produzidas. Ressalta-se a palavra do policial Cláudio, que de maneira segura e convincente, descreveu com detalhes como ocorreu a abordagem dos acusados, bem como de que forma ocorreu a localização e a apreensão da droga trazida pelo acusado Mateus e também de que maneira o policial Luciano apreendeu entorpecentes em posse do corréu Paulo. Não há nos autos qualquer elemento idôneo hábil a retirar a credibilidade do testemunho policial.

Como já se decidiu "é bem sabido que não furta a lei validade aos depoimentos de policiais, tanto que sequer os isenta do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, se vierem sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre é conferir a tais declarações o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, conferindo-lhes, ou não, segundo seu livre poder de convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética, de veracidade a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Nem teria sentido conferir a

lei determinada tarefa ao agente de segurança para, ao depois, quando ele fosse convocado a prestar contas de sua atuação, negar-lhe valor, aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não diz a verdade" (Apelação criminal nº 112.195-3/1, Santos, Rel. Des. Canguçu de Almeida, em 07/10/1991, 2ª Câmara Criminal). Aliás, mostra-se "imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que o depoimento de policiais responsáveis pela segurança pública, não podem ser desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem função de salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento" (TJSP - AP - Rel. Walter Guilherme - j. 10.03.98 - JTJ 214/284). Ademais, o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de manifestar-se favoravelmente à validade desses depoimentos. A propósito, registro: "Tóxicos - Tráfico - Prova testemunhal: Depoimento de policiais. A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas. Precedente" (STF - 2ª T. - HC nº 74.522-9/AC - Rel. Mm. Maurício Correa - DJU 13/12/96, pág. 50.167).

"Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais - Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF 1ª Turma - HC nº 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189).

Frise-se que o depoimento do policial civil colhido durante a instrução criminal mostra-se coerente e harmônico quanto às circunstâncias em que se deu a abordagem dos acusados e a localização das drogas destinadas ao tráfico com o corréu Mateus, e encontra-se em verdadeira consonância com as declarações prestadas perante a Autoridade Policial.

Embora a confissão não seja prova dotada de caráter absoluto, no presente caso, a versão de Mateus está em conformidade com os demais elementos coligidos aos autos, tendo sido confirmada pelo depoimento da testemunha policial Cláudio em Juízo. Destaque-se que a testemunha policial ressaltou ter visualizado, durante o monitoramento por ele realizado com seu parceiro policial Luciano, o acusado Mateus portando uma sacola, bem como asseverou ter visto o momento em que um indivíduo aproximou-se de Mateus, que, então, realizou a venda de entorpecente. Consignou a testemunha Cláudio que, na sacola portata pelo acusado Mateus, foram encontradas diversas porções de entorpecentes variados, além de dinheiro. Note-se que não há qualquer dúvida de que a sacola contendo drogas efetivamente estava em posse do acusado Mateus, que sequer tentou fugir do local, nem mesmo dispensou o objeto, não havendo, também, dúvidas de que os entorpecentes pertenciam a Mateus.

Frise-se que o acusado Mateus admitiu que as drogas apreendidas na sacola eram de sua responsabilidade, declarando que elas lhe eram entregues por um terceiro indivíduo - que não Paulo -, que estava ao seu lado e conseguiu evadir-se quando da abordagem policial.

Dessa forma, pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do acusado Mateus, evidencia-se, pois, a realização do tráfico por ele.

Em arremate, a intenção mercantilista do corréu Mateus deriva da natureza, variedade, grande quantidade e demais circunstâncias em que a droga e também o dinheiro foram apreendidos.

De mais a mais, "para caracterização do tráfico de entorpecentes não é

indispensável a prova do ato de comércio, podendo ser ele deduzido de elementos variados como as circunstâncias da prisão, a quantidade de entorpecente, o local da infração etc." (TJRJ – AC 1.327/92 – Rel. Adolphino A. Ribeiro – RDTJRJ 20/310). De outra banda, não há nos autos elementos suficientes para embasar a condenação do corréu Paulo quanto ao crime de tráfico de drogas.

É certo que a testemunha policial Cláudio bem relatou ter visto o acusado Paulo ao lado de Mateus, em local já conhecido pela ocorrência do tráfico de drogas.

Da mesma forma, consignou a testemunha policial que o corréu Paulo empreendeu fuga no momento da abordagem, tendo sido detido na sequência pelo policial Luciano, em posse de 25 pedras de crack.

Porém, o depoimento oferecido pela testemunha policial em Juízo não trouxe maiores detalhes acerca da efetiva prática do tráfico de drogas pelo acusado Paulo.

Pelo teor de seu depoimento é possível apenas ter a convicção de que o réu Paulo efetivamente foi detido na posse de entorpecente.

Veja-se que a testemunha policial narrou ter visto o acusado Mateus, que efetivamente vendeu drogas a um terceiro indivíduo que dele aproximou-se, bem como asseverou ter visto, ao lado de Mateus, o acusado Paulo, mas consignou que não viu este último perfazer nenhuma conduta relacionada à venda das drogas.

A testemunha policial não presenciou e não descreveu qualquer outra conduta do réu Paulo que indicasse a traficância, nem mesmo qualquer conduta que indicasse auxílio mútuo entre ambos os réus na prática do crime.

Assim, embora o acusado Paulo tenha sido detido em posse de 25 porções de entorpecentes, certo é que os demais elementos de provas coligidos aos autos não trazem a certeza necessária acerca da autoria deste acusado no delito de tráfico de drogas.

Destaque-se, ainda, que o acusado Mateus, em seu interrogatório, declarou que o indivíduo que lhe fornecia as drogas e estava ao seu lado praticando o crime não era Paulo, dizendo que, momentos antes, havia vendido ao corréu Paulo - por R\$100,00 que teriam sido entregues por Paulo ao comparsa não identificado de Mateus - 20 pedras de crack, dando a ele, como regalo, mais cinco porções da mesma droga. Finalmente, frise-se que a versão fornecida pelo acusado Paulo encontra-se em harmonia com aquela apresentada pelo corréu Mateus e não foi amplamente afastada por nenhuma prova produzida sob o crivo do contraditório.

Dessa forma, se de um lado a palavra do policial não pode ser desconsiderada como elemento de prova quanto à autoria do crime de tráfico de drogas, certo é que há dúvidas relevantes que, no presente caso, devem ser resolvidas em favor do acusado Paulo.

Há que se considerar, no presente caso, que as drogas apreendidas em posse do acusado Paulo destinavam-se ao seu próprio uso.

Por isso, entende-se seja o caso de desclassificar a conduta do réu Paulo de tráfico de drogas para aquela prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Outrossim, quanto ao delito tipificado no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, verifica-se não há prova suficiente produzida sob o crivo do contraditório que possa embasar um decreto condenatório.

Não restou demonstrado que os acusados efetivamente estavam associados entre si, organizando-se previamente para a prática do delito de tráfico de drogas, pois nem mesmo há demonstração da prática do delito de tráfico de drogas pelo acusado Paulo. Não havendo prova suficiente, portanto, sobre o delito tipificado no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, devem ser os acusados absolvidos desta imputação, pois, como se sabe, a dúvida sempre deve ser resolvida em favor dos réus.

Diante do cotejo probatório trazido aos autos, de rigor a condenação do acusado Mateus pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos da fundamentação exposta.

Parcialmente procedente a ação penal, passo a dosar a pena do delito de tráfico de drogas praticado pelo acusado Mateus.

Diante da natureza e variedade das drogas apreendidas, circunstâncias que demonstram a maior periculosidade do réu, justifica-se o aumento da pena em 1/6, ficando a pena-base fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal.

Na segunda fase de fixação da pena, verifico que o delito foi cometido em ocasião de calamidade pública. Em que pese a vigência somente até 31 de dezembro de 2020 do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, em âmbito federal, verifica-se que o estado de calamidade pública no Estado de São Paulo, decorrente da pandemia do COVID-19, foi reconhecido por meio do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, que ainda se encontra em vigência diante de sucessivas prorrogações. Portanto, em âmbito estadual, mantiveram-se vigentes as normas referentes ao reconhecimento do estado de calamidade pública. A agravante tem caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência. De qualquer forma essa circunstância não pode ser ignorada, pois o isolamento social e a quarentena, em razão da pandemia, facilitam a prática do crime. Impõe-se, portanto, o aumento de pena pelo reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Contudo, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ficam as circunstâncias compensadas. Não há como reconhecer-se a circunstância atenuante da menoridade relativa, aduzida pela Defesa, pois se depreende dos autos que Mateus já havia completado 21 anos à época dos fatos.

Na terceira fase da dosimetria da pena, não há causa de aumento a ser reconhecida. Em que pese a grande quantidade de entorpecentes apreendidos, forçoso, excepcionalmente, diante das peculiaridades do caso, aplicar-se a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que o réu é primário, não ostenta Maus antecedentes e não há elementos nos autos que possam indicar que o réu se dedica a atividades criminosas ou que integre organização criminosas.

Contudo, diante da quantidade de drogas apreendidas, considerando os critérios previstos no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, a diminuição se dará em 1/6, ficando a pena em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, no valor mínimo legal. Com efeito, não caracteriza ofensa ao princípio do *ne bis in idem* a utilização da natureza da droga como circunstância judicial negativa para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria e o reconhecimento da grande quantidade de drogas, na terceira fase, para fins de modular ou afastar a redutora prevista na Lei de Drogas.

Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA. MODULAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DA DROGA. BIS IN IDEM NÃO VERIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA ALTERNATIVA. PENA SUPERIOR A 1 (UM) ANO. UMA RESTRITIVA E OUTRA DE MULTA MAIS BENÉFICA. IMPROCEDÊNCIA. FACULDADE DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena, como atividade discricionária vinculada do julgador, será revista apenas nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, quando não observados os parâmetros estabelecidos na legislação de regência e o princípio da proporcionalidade. 3. Não configura *bis in idem* a aferição desfavorável da natureza da droga (cocaína), na primeira etapa da dosimetria, para majorar a pena-base e a utilização da quantidade (567 gramas) na escolha da fração do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (Precedentes do STJ e do STF). 4. Fixada a sanção corporal em patamar superior a 1 (um) ano, compete ao julgador a escolha do modo de aplicação da benesse legal prevista no art. 44, § 2º, segunda parte, do CP, substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos (Precedente). 5. Ordem não conhecida. (HC 386934 / SC HABEAS CORPUS 2017/0020104-9, Relator(a): Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 16/03/2017, PUBLIC 23/03/2017 - g.n.).

Torno essa pena definitiva na ausência de modificadoras.

Verifica-se, portanto, fixação de pena em patamar superior a quatro anos o que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Também incabível o sursis.

Considerando as peculiaridades do presente caso e as condições previstas no artigo 59 do Código Penal, cuidando-se de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, cujo aspecto altamente nocivo à sociedade em geral ninguém desconhece, por certo que não se afigura socialmente adequada e recomendável à situação a aplicação de penas alternativas ou outros benefícios que, por sinal, implicaria sensação de impunidade e incentivo à prática delituosa, frustrando-se a expectativa social, que exige e espera, em tais condições, efetiva e eficaz resposta à criminalidade cada vez mais crescente, motivos pelos quais fixo o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena.

Finalmente, não há se cogitar da aplicação imediata do disposto no §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal nesta seara, vale dizer, sem elementos concretos a respeito do seu comportamento no cárcere, a recomendar a prudência e o bom senso que a questão relacionada à detração penal seja analisada por primeiro pelo Juízo das Execuções.

A lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o Código Penal e não o Código de Processo Penal. A progressão de regime vem, por sua vez, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada a progressão, imprescindível que sejam analisados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o do Juízo das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.

Nesse sentido:

"Apelação - Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria bem demonstradas - Testemunho dos agentes policiais, sob o crivo do contraditório, ratificando a prova administrativa - Ré confessa, ademais - Não incidência do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, uma vez que não preenchidos os requisitos subjetivos - Precedentes - Pena de multa que se corrige - Mínimo erro material do r. juízo em detrimento da apelante - Regime fechado justificado - Impossibilidade de substituição da física por restritiva de direito - Detração - Matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais - Recurso desprovido, com observação." (TJSP - Ap. Nº 0003591-97.2014.8.26.0577 - 4ª Câmara - Rel. Ivan Sartori - J. 28.04.2015 - grifei)

Deve-se ressaltar, ainda, que a detração neste momento processual causaria a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para:

1. CONDENAR o réu MATEUS LOPES DA SILVA, qualificado nos autos, às penas de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, no valor mínimo legal, por incurso no artigo 33, caput e §4º, da Lei nº 11.343/06 c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, bem como para ABSOLVÊ-LO da imputação que lhe foi feita de ter praticado o delito previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, o que faço com supedâneo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

2. DESCLASSIFICAR a conduta do réu PAULO ALBERTO QUINTINO DOS SANTOS, qualificado nos autos, para a de posse de drogas para uso próprio. Em consequência, sendo este Juízo Comum incompetente na Comarca para o julgamento dessa infração de menor potencial ofensivo, extraiam-se cópias integrais dos autos e proceda-se ao devido encaminhamento ao Juizado Especial Criminal local, com as providências de praxe, arquivando-se estes autos quanto a este delito imputado a PAULO;

3. ABSOLVER o acusado PAULO ALBERTO QUINTINO DOS SANTOS, qualificado nos autos, da imputação que lhe foi feita de ter praticado o delito previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06, o que faço com supedâneo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Quanto ao acusado PAULO, diante da desclassificação e da absolvição operadas, concedo a ele o direito de recorrer em liberdade.

Nego ao réu MATEUS o direito de apelar desta em liberdade, estando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, considerando-se os malefícios inerentes ao tráfico de drogas ao meio social.

Destaca-se, ainda, a quantidade, a natureza e a variedade de entorpecentes apreendidos com o acusado, o que, como também já ressaltado, demonstra que não se trata de pequeno traficante, mais sim de um grande disseminador dos entorpecentes. Finalmente, não há qualquer alteração da situação fática ou jurídica que justifique a reconsideração da decisão que decretou a custódia cautelar no presente feito, mormente no momento em que foi proclamado culpado em primeiro grau de jurisdição. Portanto, verifico que ainda estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo de rigor manter a prisão preventiva, cumprindo-se, outrossim, o disposto no parágrafo único do artigo 316 do mesmo diploma legal. Recomende-se o réu MATEUS na prisão em que se encontra.

Decreto o perdimento dos valores apreendidos nos autos em favor da União, com fundamento no artigo 63 da Lei nº 11.343/06.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Vicente, 08 de abril de 2022.

ALEXANDRE TORRES DE AGUIAR

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA